

1500613-91.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... para a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, ou, em caso de condenação pelo delito de tráfico, requer a fixação da pena nos termos do art. 42, do referido Diploma Legal, bem como a revogação da prisão preventiva (fls. 267/270).

A defesa de ROGÉRIO requereu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500613-91.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500613-91.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE ALVES MACHADO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

ROGÉRIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA e LUIS FELIPE ALVES MACHADO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, caput, este do Código Penal, bem como ROGÉRIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 5 de maio de 2022, por volta das 15h45min, na Avenida Dona Gertrudes, 680, Alvinópolis, nesta cidade e Comarca de Atibaia, agindo em concurso de agentes, com unidade de designios, fazendo uso do veículo automotor Fiat/Uno Mille, placas CRF2396, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 41 porções de cocaína e uma de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, ROGÉRIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

transportava, em proveito próprio, um aparelho de telefonia celular, Xiaomi, ciente de que se tratava de coisa produto de crime (conforme RDO nº 741338/2022, Delegacia Eletrônica, registrado em 03/04/22).

Segundo foi apurado, os réus, que estavam encostados no automóvel de ROGÉRIO, acima descrito, traziam consigo os entorpecentes, para fins de tráfico ilícito, quando, ao notarem a presença de uma viatura, tentaram se evadir. É certo, ainda, que antes, LUIS arremessou para o interior do automóvel, através da janela que estava aberta, uma sacola.

Diante de tais atitudes altamente suspeitas, os policiais foram ao encalço de ambos e fizeram a abordagem. Com efeito, em busca pessoal, acharam com ROGÉRIO cinco papелotes de cocaína e uma porção de maconha, além de um aparelho celular. Já com LUIS foram achados mais seis papелotes de cocaína, além de um aparelho celular e da quantia de R\$ 140,00, em notas diversas e moedas.

Na sequência, feita a busca veicular, os policiais acharam o restante das drogas dentro do saco plástico que havia sido dispensado.

Indagados, ambos os réus confessaram a traficância pelo local.

Ademais, feitas pesquisas de praxe em relação aos celulares apreendidos, verificou-se que o aparelho que estavam na posse de ROGÉRIO era produto de furto (conforme RDO nº 741338/2022, Delegacia Eletrônica, registrado em 03/04/22), não tendo ele apresentado qualquer justificativa para a posse do bem de origem espúria.

Já na delegacia, os réus optaram por ficar calados.

Em laudo de constatação preliminar, verificou-se que as substâncias apreendidas são entorpecentes constantes da lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

O flagrante de LUIS foi convertido em preventiva, tendo o corréu ROGÉRIO sido posto em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares (fls. 82/84).

Os réus foram notificados (ROGÉRIO às fls. 134 e LUIS às fls. 136), e apresentaram defesas prévias (LUIS às fls. 147/150 e ROGÉRIO às fls. 171/188), que foram afastadas, sendo recebida a denúncia (fls. 196/200).

Os réus foram citados (ROGÉRIO às fls. 243/244 e LUIS às fls. 247).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo os réus interrogados ao final (fls. 249/250).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 251/258).

A defesa de LUIS requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando, em síntese, que não há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, ou, em caso de condenação pelo delito de tráfico, requer a fixação da pena nos termos do art. 42, do referido Diploma Legal, bem como a revogação da prisão preventiva (fls. 267/270).

A defesa de ROGÉRIO requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas de que ou réu concorreu para a prática dos crimes, ou, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando que não há prova suficiente para a condenação; subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06 ou, em caso de condenação pelo delito de tráfico, requer a concessão do benefício do art. 33, §4º, da referida Lei, com fixação da pena no mínimo legal, bem como o direito de apelar em liberdade (fls. 277/292).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 09/13), no auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16/17), nas fotografias (fls. 43/48), no laudo toxicológico (fls. 153/164), e na prova oral produzida.

As autorias criminosas devem ser imputadas aos réus que, interrogados extrajudicialmente, optaram por permanecerem em silêncio (fls. 05/06).

Em juízo, interrogado, disseram o seguinte:

O réu LUIS negou os fatos. Questionado por que acha que está sendo acusado, disse que é usuário de drogas; parou com essa vida há um bom tempo, estava trabalhando honestamente, com pintura, e jamais achou que ia "cair" por essas coisas, que não estava fazendo; questionado por que, assim como ROGÉRIO, falou para os policiais que estavam traficando, disse que não falaram que estavam traficando; os policiais acharam quatro papелotes de cocaína consigo, sendo que a sacola que os policiais falaram que foi jogada pela janela do carro não existiu, e essa quantidade de droga não estava consigo; questionado de onde saiu essa droga, disse que não sabe, pois estava com quatro papелotes de cocaína, uma porção de maconha, sendo que levava R\$ 80,00; questionado o que foi encontrado com ROGÉRIO, disse que salvo engano, um celular, sendo que foi pego um celular consigo também; questionado de quem era o carro, disse que era de ROGÉRIO; questionado com quantas porções de droga estava, disse que quatro papелotes de cocaína; questionado sobre constar, no inquérito, às fls. 47, uma foto de toda a droga que foi encontrada, todas exatamente iguais, e como os policiais acharam ou inventaram drogas exatamente iguais às que estavam consigo, disse que no depoimento que viu, os policiais falaram que a sacola foi jogada pela janela de trás do carro, e que acharam mais seis papелotes consigo, mas, se realmente fosse traficante, mas não é, não jogaria a sacola e as drogas que estavam consigo; o que acharam consigo, realmente, foram os quatro papелotes de cocaína, sendo que não sabe de onde veio a sacola; questionado se não sabe explicar como apareceram drogas idênticas às que estavam consigo, disse que não sabe explicar; trabalha como ajudante de pintura; ROGÉRIO mora perto da sua casa; questionado por que estava com ele naquele local, disse que no domingo, estavam em um churrasco na casa de um amigo, Bruno, ao lado de um bar; foi dar uma volta com ROGÉRIO no Bairro Cerejeiras e, quando estavam voltando para casa, passaram pela Av. Gertrudes, e iam passar em uma farmácia, sendo que, quando pararam o carro, a viatura os avistou, e pediu que descessem do carro; trabalha como ajudante de pintura, e ganhava R\$ 400,00 por semana; estudou até o primeiro colegial; já foi processado por tráfico, e estava cumprindo regime aberto por assalto; às reperguntas da defesa de ROGÉRIO, questionado há quanto tempo o conhecia, disse que fazia pouco tempo, sendo que pediu trabalho a ele, que deu uma oportunidade; questionado se ROGÉRIO era conhecido como bom profissional de pintura, disse que muita gente o conhecia, e dava trabalho para ele; questionado se sabe se ele era usuário de entorpecentes, disse que não sabe; questionado se ROGÉRIO reside com a família dele no bairro, disse que mora com a família (fls. 249/250).

O réu ROGÉRIO negou os fatos. Disse que não estava ciente de que o celular era produto de furto, sendo que comprou o aparelho em um bar, na sexta-feira; questionado quanto às drogas, disse que realmente estava com as drogas no bolso, sendo cinco papелotes, e uma "bucha" de maconha, que comprou para usar; questionado de onde saíram as outras drogas, disse que desconhece; questionado sobre as drogas que foram apresentadas na Delegacia serem todas absolutamente iguais, e de onde os policiais tiraram drogas exatamente iguais às que estavam consigo, disse que não sabe dizer, e assume apenas as que comprou; questionado por que os policiais falaram que confessou, assim como LUIS, que estavam traficando, disse que não estava traficando, sendo que comprou para uso próprio, pois é viciado; questionado por que não falou isso na Delegacia, disse que não sabe; questionado se está sendo acusado de tráfico e não quis falar nada na Delegacia, disse que trouxeram vários papéis para assinar, sendo que mal sabe ler, e não sabia o que estava assinando, e descobriu depois que assinou; conhece LUIS do seu bairro, sendo que ele foi pedir emprego; questionado por que estava com ele na data dos fatos, disse que estava no churrasco de um amigo, e chamou LUIS para subir, depois voltaram; iam parar na farmácia para pegar um neosoro e, nesse meio tempo, a polícia os "enquadrrou", e foram para a Delegacia; trabalha há mais de dez anos com pintura, sendo que recebe R\$ 600,00 por semana; estudou até a terceira série; não foi processado anteriormente; questionado sobre ter dito que é viciado, e se já fez algum tratamento, disse que ainda não; não consegue, por causa da sua família; questionado de quem era o carro em que estava, disse que era seu, sendo que tinha o comprado para trabalhar; questionado de onde saiu o celular, disse que comprou no

"Bar do Lino", em uma sexta-feira, de um conhecido; questionado se tem algum documento de compra, disse que não tem nada; questionado de quem comprou, e quanto pagou, disse que pagou R\$ 600,00, tendo comprado de um conhecido, que nunca mais voltou ao local; questionado se é conhecido, mas não sabe quem é, disse que o conheceu no bar, sendo que ele trabalhava, e de vez em quando estava no bar; às perguntas da sua defesa, questionado qual tipo de droga usava, disse que cocaína e maconha; questionado quanto pagou pela droga na data dos fatos, disse que tinha R\$ 90,00, pagou R\$ 60,00 pela droga e colocou R\$ 30,00 de gasolina; questionado há quantos anos trabalha com pintura, disse que há dez anos; questionado há quanto tempo conhecia LUIS, disse que há um mês e pouco; questionado se LUIS morava próximo à sua casa, disse que não muito próximo; questionado se, em algum momento, assumiu para os policiais que estaria traficando, disse que de forma alguma; questionado se chegou a relatar para os policiais que era usuário, disse que chegou a relatar que tinha comprado para usar; questionado se conhecia a pessoa de quem comprou o celular, disse que era um conhecido que sempre estava no "Bar do Lino", nos finais de semana; um dia, ele ofereceu o celular, então comprou, sendo que não sabia que era roubado; tem três filhos, sendo uma de três anos de idade, uma de oito e um de treze; é o provedor da sua família, e sua esposa está desempregada atualmente; às perguntas da defesa de LUIS, questionado se sabe quanta droga ele levava, disse que não; questionado se estavam dentro ou fora do carro quando foram abordados, disse que estava descendo do carro, pois ia atravessar a rua para ir à farmácia, quando os policiais pararam, sendo que LUIS estava dentro do veículo (fls. 249/250).

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A testemunha Romário Costa de Souza, policial militar, ouvido às fls. 249/250, disse que a equipe estava em patrulhamento, quando avistou dois indivíduos próximos a um veículo Fiat Uno, ocasião em que LUIS, ao avistar a presença policial, arremessou algo que estava com ele para dentro do interior do veículo; a equipe procedeu com a abordagem, da qual os réus tentaram se desvencilhar; em revista pessoal, foram localizados com ROGÉRIO maconha, uma pequena quantidade de cocaína, e um celular; com LUIS foi encontrados cocaína e dinheiro; em busca veicular, foram localizados entorpecentes; indagados, os réus confessaram o tráfico, alegando que estavam passando por dificuldades financeiras; feita pesquisa quanto ao celular, constatou que havia um BO relativo a um furto ocorrido em data anterior; diante disso, os réus foram conduzidos à Delegacia Distrital de Atibaia; questionado se ambos confessaram, disse que "ambos"; às perguntas da acusação, questionado com quem estava o celular que tinha queixa de furto, disse que com ROGÉRIO; questionado se ele falou alguma coisa sobre a origem do celular, disse que ele falou que havia comprado, tendo dado detalhes de algum conhecido, e que futuramente poderia esclarecer a compra do aparelho; questionado se ele falou quanto pagou, disse que não se recorda; às perguntas da defesa de LUIS, questionado quantas pessoas integravam sua equipe, disse que estava juntamente com o CBPM Jurandyr, mas teve o apoio de mais dois policiais, sendo uma policial feminina, e um masculino; questionado quem avistou os réus, disse que os quatro avistaram; a outra equipe avistou, sendo que estava na avenida, e avistou também, então, de pronto, compareceu ao local, e realizou o procedimento; às perguntas da defesa de ROGÉRIO, questionado se os réus estavam em movimento ou parados no local, quando foram avistados, disse que a princípio, eles estavam parados, e tentaram deixar o local, tendo o veículo se movimentado na via, dando a volta, tendo sido abordado; a equipe dirigiu-se até a via para averiguar uma denúncia de alteração em caixa eletrônico na Av. Dona Gertrudes, razão pela qual havia mais de uma equipe no local; questionado se havia mais alguém no local onde os réus estavam parados, disse que a via é bastante movimentada, e há vários bares no local, sendo que havia muitas pessoas nas proximidades, porém não tinham relação com a abordagem, sendo que não havia como abordar todos; a via em questão é conhecida por ser bastante movimentada; questionado se conversou com ROGÉRIO, disse que conversou com os dois abordados; questionado se ROGÉRIO chegou a mencionar se era usuário, disse que no momento dos fatos, não; ROGÉRIO falou que estava acompanhando seu parceiro; questionado a quem pertencia o veículo, disse que salvo engano, ROGÉRIO afirmou que

o carro era dele, no entanto, o veículo não estava em seu nome; questionado se foi feita busca no carro, disse que sim; questionado se foi localizada alguma anotação do tráfico, ou algo do tipo, disse que não se recorda de anotações; questionado se foi quem vasculhou o aparelho celular que estava com o réu, disse que o celular é solicitado somente para a pesquisa do IMEI, que é equivalente ao chassi de um veículo; questionado se não foi verificado se havia alguma mensagem com teor de tráfico no aparelho do réu, disse que de forma alguma; questionado se conhecia os réus anteriormente, disse que não conhecia; questionado se, após os fatos, chegou a abordar ROGÉRIO mais alguma vez, disse que o abordou há quatro ou três dias, sendo que ele estava trabalhando; questionado se lembra qual era a quantidade de droga encontrada com ROGÉRIO, disse que salvo engano, eram cinco papелotes de cocaína, uma porção de maconha, e o celular.

A testemunha Jurandyr Aparecido de Oliveira, policial militar, ouvido às fls. 249/250, disse que estava se deslocando para atender a uma ocorrência relacionada a caixa eletrônico, na agência bancária da Avenida Dona Gertrudes; chegando próximo ao local, visualizou indivíduos ao lado do veículo Uno, sendo que, um dos indivíduos, ao notar a aproximação da equipe, arremessou um pacote para dentro do automóvel, e tentou sair do local, sendo abordado, ocasião em que outra viatura estava prestando apoio, em razão da ocorrência bancária; seu parceiro realizou buscas pessoais e veicular; em seguida, houve outra ocorrência, então a outra viatura necessitou sair, sendo que ficou com seu parceiro no local; foram encontrados com os indivíduos, drogas, dentro de uma embalagem de cigarro, sendo que um dos abordados estava com um celular, que constou como produto de furto ocorrido em data anterior, mediante consulta do IMEI; diante disso, os réus foram conduzidos ao DP; questionado se lembra quais drogas estavam com cada um dos réus, disse que detalhadamente, não se recorda, mas sabe que ambos estavam com drogas na carteira de cigarros, sendo que, dentro do veículo, no saco plástico que foi jogado por um dos réus, também havia drogas; questionado o que os réus disseram, disse que eles disseram que estavam traficando drogas, e que um deles prestava apoio, para avisar quanto à chegada da viatura, ou aproximação de qualquer pessoa que pudesse atrapalhar o comércio de drogas; questionado se lembra com qual dos réus estava o celular, disse que não lembra, mas um dos celulares constava como produto de furto; questionado se já conhecia os réus de outras abordagens, disse que não conhecia nenhum deles; às reperguntas da defesa de LUIS, questionado se havia alguma PM feminina, disse que tinha, na equipe que estava junto; para averiguar ocorrência envolvendo banco, sempre vão duas ou mais viaturas; quando a busca foi iniciada, a viatura de apoio precisou sair para prestar apoio em outra ocorrência; questionado se os réus tentaram fugir, disse que não; às reperguntas da defesa de ROGÉRIO, questionado se havia outras pessoas nas proximidades, disse que a avenida é movimentada, pois há vários comércios, frequentados principalmente no período noturno, no entanto, relacionados à abordagem, apenas os réus estavam ao lado do veículo, sendo que não havia outras pessoas com eles na abordagem; questionado se chegou a interrogar ROGÉRIO, disse que foi feito o procedimento na Delegacia, mas, no local, o réu foi indagado sobre a droga, ocasião em que ambos falaram que estavam traficando drogas, e que um deles era o apoio, inclusive para sair com o veículo; questionado se os réus foram indagados separadamente, disse que não, foram indagados juntos, sendo que, inclusive, não houve discussão, tendo os réus falado a verdade por livre e espontânea vontade; questionado se o celular foi vasculhado, disse que não; apenas realizou a pesquisa quanto ao número de IMEI, sendo que respeita o sigilo e privacidade quanto ao celular do abordado; questionado se ROGÉRIO mencionou que seria usuário, disse que não, ele falou que estava traficando, enquanto o outro estava prestando apoio, não tendo falado que era usuário, nem que estava passando por tratamento, ou algo do tipo; questionado se lembra de que lado do carro foi jogado o pacote, disse que não se recorda desse detalhe; questionado se lembra quem jogou o pacote, disse que não se recorda; na abordagem, foram feitas buscas pessoal e veicular; questionado o que continha a sacola, disse que havia droga, mas não sabe especificar a quantidade; questionado se chegou a abordar ROGÉRIO após os fatos, disse que não.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

Os réus, interrogados em solo policial, optaram por permanecer em silêncio, sendo que em juízo, negaram os fatos, narrando, em síntese, o seguinte:

LUIS disse que é usuário de drogas, e não estava traficando, sendo que parou com essa vida há um bom tempo. Disse, também, que não falou para os policiais que estava traficando, e que foram achados quatro papelotes de cocaína e uma porção de maconha consigo, além de R\$ 80,00, mas não sabe de onde veio a sacola que os policiais falaram que foi jogada pela janela do carro. Disse, ainda, que estava com ROGÉRIO em um churrasco, e saíram para dar uma volta, sendo que, quando estavam voltando, iam passar em uma farmácia, e quando pararam o carro, foram abordados pelos policiais.

ROGÉRIO disse que não estava traficando, e estava com drogas no bolso, sendo cinco papelotes de cocaína e uma porção de maconha, para uso próprio, pois é viciado, sendo que não sabe dizer de onde saíram as outras drogas, exatamente iguais às que estavam consigo. Disse, também, que não falou na Delegacia, mas não sabe porquê, e que trouxeram vários papéis para assinar, mas não sabia do que se tratava, tendo descoberto apenas após ter assinado. Alegou, ainda, que estava em um churrasco com LUIS, saíram e, ao pararem em uma farmácia, foram abordados pelos policiais. Disse, também, que comprou o celular de um conhecido, em um bar, mas não possui comprovante da compra, e não sabia que o aparelho era produto de furto.

No entanto, as narrativas dos réus restaram fragilizadas ante as demais provas produzidas, estando claro que os réus, com suas versões, visam, tão somente, se eximir da responsabilidade pelos crimes praticados. Senão, vejamos:

Os policiais, cujos depoimentos se mostraram firmes e consistentes, disseram o seguinte:

Romário narrou que foi atender a uma ocorrência, quando avistou os réus próximos a um veículo Fiat Uno, ocasião em que LUIS, ao avistar a equipe, arremessou algo para o interior do veículo. Narrou, também, que em revista pessoal, foram encontradas, com os réus, drogas, consistentes em maconha e cocaína, tendo sido encontrado, também, um celular, com ROGÉRIO, sendo que, em busca veicular, foram localizados mais entorpecentes. Narrou, também, que os réus confessaram que estavam traficando, alegando que estavam passando por dificuldades financeiras. Disse, ainda, que quanto ao celular encontrado com ROGÉRIO, constava um registro de furto, ocorrido em data anterior. Disse, também, que ROGÉRIO não falou que era usuário no momento da abordagem.

O policial Jurandyr disse que estava se deslocando para a atender a uma ocorrência, quando visualizou os réus ao lado do veículo Uno, ocasião em que um deles, ao notar a aproximação da equipe, arremessou um pacote para dentro do automóvel, e tentou sair do local, sendo abordado. Disse, também, que foram encontradas drogas com os réus, e um celular, que constava como produto de furto, sendo que, no pacote jogado dentro do carro, havia mais entorpecentes. Narrou, ainda, que os réus confessaram que estavam traficando, e que um deles estava prestando apoio, para avisar sobre a chegada da viatura, ou de qualquer pessoa que pudesse atrapalhar o comércio de entorpecentes. Disse, também, que ROGÉRIO não falou que era usuário, e sim admitiu que estava traficando.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexistente qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo

simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, interesse maior na gratuita acusação dos réus.

Assim, verifica-se que as negativas dos réus não encontram qualquer respaldo nos autos, já que foram presos em flagrante em posse de considerável quantidade de drogas. E embora tenham afirmado que são usuários, não souberam explicar porque foram apreendidas drogas exatamente iguais às que levavam consigo (fls. 43/48), sendo evidente a prática, por ambos os réus, do tráfico de entorpecentes, tanto que confessaram durante a abordagem. Ademais, embora tenham alegado que são "apenas" usuários, não fizeram qualquer prova disso, nem sequer fizeram tal alegação quando foram abordados, conforme depoimentos dos policiais, nem na Delegacia, onde optaram por permanecer em silêncio.

Além disto, o tipo do art. 33 não faz menção a 'uso próprio'. Tal menção é feita no art. 28, ambos da Lei 11.343/06. Destarte, se o réu acusado de tráfico pretende que se aceite que a posse da droga era para uso próprio, com desclassificação para o art. 28, e consequente desfazimento da conclusão de que se trata de traficante, terá que provar a alegada destinação. E esta prova cabe à defesa, não à acusação. Na hipótese, tal prova não foi feita.

E ainda que tivesse sido feita, o fato de ser usuário não afastaria o tráfico devidamente comprovado. Assim já se decidiu:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

O crime de receptação, praticado pelo réu ROGÉRIO, também restou devidamente comprovado, já que foi preso em posse de um celular produto de furto (v. depoimentos dos policiais e boletim de ocorrência às fls. 219/220), sendo evidente que o réu tinha plena ciência da origem espúria do bem.

Além disto, em casos de receptação, há inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a licitude da aquisição do bem encontrado em seu poder, no entanto, não fez nenhuma prova ao seu favor, seja apresentando um comprovante da suposta compra, seja arrolando como testemunha a pessoa que supostamente lhe vendeu o bem.

Neste sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. POSSE DO BEM SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. 1) Absolvição Atipicidade Descabimento - Provas orais que demonstram a ciência do réu quanto à origem criminosa do bem receptado, o que se extrai também pelas provas indiciárias (artigo 239 do Código de Processo Penal) Tendo o acusado sido encontrado na posse do bem, há inversão do ônus da prova, competindo àquele apresentar escusa legítima para justificar a posse do bem cuja origem criminosa se apurou - Precedentes jurisprudenciais - Condenação mantida. 2) Pena - Dosimetria - Pena-base - Elevação - Cabimento - Bem receptado de alto valor - Maior ousadia pela facilitada vigilância repressiva quanto a automóveis - Periculosidade revelada pela

tentativa de fuga. Pena mantida" (TJ-SP 0091942-80.2011.8.26.0050; Relator: Alcides Malossi Junior; Data de Julgamento:04/02/2016; 8ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 11/02/2016) (Destaquei).

E ainda:

"DELITO DE RECEPÇÃO. A posse injustificada do bem, encontrado em poder do réu, faz presumir a autoria, competindo ao possuidor demonstrar que obteve a motocicleta de modo lícito. Caso contrário, a presunção transmuda-se em certeza. O ônus da prova tem aplicação inversa. Assim, não comprovada a versão apresentada, resta configurado o delito. Condenação mantida. Pena alterada. Apelo parcialmente provido, por maioria". (Apelação Crime Nº 70055231948, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 01/08/2013) (destaquei).

Cabe, sobre o tema, apontar que "(...) a perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, da origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive, indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM-SP-AC - Rel. Bento Mascarenhas - RT 726/666) (destaquei).

Assim, o robusto conjunto probatório foi plenamente apto a comprovar que os réus, de fato, praticaram os delitos, nos exatos termos da denúncia, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1 - Réu LUIS

O réu é duplamente reincidente, conforme se verifica às fls. 63/66 e 67/70.

Considerarei como maus antecedentes o proc. 1500982-90.2019 (fls. 67/68 - roubo), sendo a outra reincidência considerada como agravante.

Não há que se falar em bis in idem na consideração da reincidência e dos maus antecedentes, porque como já se decidiu, se o réu for duplamente reincidente, uma das circunstâncias pode ser considerada como agravante e a outra, como circunstância judicial para aumento da pena-base (TACRIM, ACrim 455.109, 8ª Câm., em 18-12-99, rel. Silva Pinto).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...)" (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-la. Quanto à sua conduta social, lamentável. Mesmo já tendo sido preso e condenado por tráfico, segue na mesma atividade ilícita, tendo praticado o crime dos autos enquanto cumpria pena, em regime aberto, pela prática de roubo, delito de peculiar gravidade, o que demonstra seu completo desprezo pelas leis e pelo convívio em sociedade. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas.

Quanto à natureza e quantidade do produto, foi encontrada, em posse do réu e de seu comparsa, bem como no veículo em que estavam, considerável quantidade de drogas, totalizando 41 porções de cocaína, bem como maconha, o que merece maior reprovação. A cocaína é entorpecente ilegalmente inserido na sociedade, causador de verdadeiras tragédias pessoais, familiares e sociais. A quantidade total de entorpecentes apreendidos seria capaz de atender um grande número de consumidores, o que não se pode admitir.

Assim, em razão dos maus antecedentes, da conduta social do réu e da natureza, quantidade e grau de nocividade das drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, 07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, posto que o réu é reincidente específico, conforme se verifica às fls. 67 (proc. 4682-29.2015 - tráfico), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 08 anos e 09 meses de reclusão, e 875 dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Evidentemente incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. O réu é reincidente específico, sendo que foi preso pelo crime dos autos quando estava cumprindo pena, em regime aberto, pela prática de roubo, sendo evidente que se dedica às atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos no parágrafo quarto.

2 - Réu ROGÉRIO

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes.

a) Quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas.

Quanto à natureza e quantidade do produto, serão utilizadas para fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo, já que o réu noticiou, em seu interrogatório, que ganha R\$ 600,00 por semana, portanto, tem renda mensal de R\$ 2.400,00. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30 avos dos rendimentos do réu, o valor deve ser fixado em R\$ 80,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. O réu foi preso, juntamente com seu comparsa, com elevada quantidade de drogas de altíssimo grau de nocividade, que não seriam confiadas a alguém que não tivesse profundo envolvimento com a traficância. Tanto é que estava associado com LUIS, duplamente reincidente, inclusive por tráfico.

Ademais, conforme relatou o policial Jurandyr, os réus disseram, durante a abordagem, que estavam traficando, e falaram que um deles prestava apoio, para avisar acerca de eventual chegada de alguma viatura, estando evidente a divisão de

funções para o tráfico, devendo, portanto, ser afastado o referido benefício, por dedicar-se o réu à atividade criminosa.

Outrossim, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas, não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a lei deu a faculdade de aplicar o benefício do parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez.

Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor.

Conforme brilhante explanação de EDILSON MOUGENOT BONFIM, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor: "Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que ele componha uma 'sinfonia criminosa musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminosa', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou

impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, verifica-se que todo "pequeno traficante" faz parte de uma imensa rede, chamada crime organizado, sendo eles a ponta danosa do iceberg, por serem quem leva a droga aos usuários, expondo a vida e saúde deles. Por tal razão, não há que se falar em tráfico privilegiado.

b) Quanto ao delito do art. 180, caput, do Código Penal:

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminoso não teve maiores consequências. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima.

Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa, diária de R\$ 80,00, nos termos da fundamentação supra.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Nos termos do art. 69, do CP, somo as penas do réu, finalizando-as em 06 anos de reclusão, e 510 dias-multa, diária de R\$ 80,00.

O regime inicial para cumprimento de pena para ambos os réus será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz,

inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a